

1500366-55.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500366-55.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500366-55.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053604/2022 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 23226018 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 640/22/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2053604 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO DE OLIVEIRA GODINHO SOARES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

LEONARDO DE OLIVEIRA GODINHO SOARES e DANIEL RODRIGUES MALTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 84/85).

Oferecida a denúncia (fls. 85/86), esta foi recebida (fls. 87) e os requeridos citados.

Após a apresentação de defesas escritas (fls. 120/121 e 126/129) o recebimento da denuncia foi ratificado (fls. 134).

Durante a instrução foram inquiridas testemunhas e interrogado o acusado DANIEL. O réu LEONARDO não foi interrogado porque revel.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ordem Constitucional estabelecida pela Carta Magna de 88 prevê que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem que seja observado o devido processo legal, nos termos do artigo 5º, inciso LIV.

O princípio do devido processo legal engloba, dentre outros, os princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais têm previsão expressa no artigo acima referido, especificamente no inciso LV, que assegura “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Nesse ponto, importante esclarecer que o direito ao devido processo legal, em sentido amplo, não pode confundido com o exercício irrestrito das faculdades processuais dispostas.

Em outros termos, embora seja conferido à parte o direito de se defender, com os meios e recursos inerentes, nem todos os requerimentos do réu importam em deferimento imediato pelo Magistrado, devendo a parte demonstrar a concreta necessidade de realização da prova pretendida, sem que isso importe em cerceamento de defesa.

Pois bem.

Pretende o réu LEONARDO a realização de exame para aferição de insanidade mental.

No entanto, em que pesem as alegações do acusado, não é o caso de deferimento do pedido de instauração de incidente, uma vez que, os documentos apresentados às fls. 155/161 não indicam que o réu seja esquizofrênico. Pelo contrário. Os medicamentos apontados nos documentos médicos são, ao que tudo indica, destinados ao tratamento de dependência química.

Com efeito, “o Juiz é o único destinatário da prova com vista à formação de sua fundamentada convicção judicial (CPP, artigo 155) e, por conseguinte, a ele compete avaliar, com exclusividade, sobre quais as provas relevantes e as impertinentes (CPP, artigos 155, 251 e 400, § 1º). Afinal, no direito processual moderno vigora o princípio da discricionariedade regrada ou mitigada, o qual está em perfeita consonância com o ordenamento e as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, já que, ao decidir sobre uma prova deverá o Juiz motivar sua decisão”.

Ademais, a prova oral produzida dá conta que o réu LEONARDO tomou paradeiro ignorado nas vésperas da audiência, fato que indica que o acusado possivelmente está praticando atos visando se esquivar da sua responsabilidade criminal.

Portanto, por não vislumbrar indicativos de comprometimento da higidez mental do acusado, INDEFIRO o pedido de realização de exame pericial de insanidade mental.

Não há questões preliminares a apreciar.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, isso porque, terminada a

instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que os acusados, de fato, praticaram o delito que lhes são imputado.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria são indúvidas, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), pelos laudos químico-toxicológicos (fls. 12/14 e 149/151), que atestam pelos resultados positivos para maconha e cocaína, pelo relatório final (fls. 72/75), bem como pela prova oral nos autos produzida.

De fato, os Policiais Civis Pedro Paulo Bassetti e Bruno Sturari Scarpelli, quando inquiridos em juízo, disseram que foram até o local dos fatos, que é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, onde realizaram breve campana e verificaram que os acusados estavam traficando drogas.

Asseveraram que puderam observar que o réu LEONARDO ficava no começo da viela, onde recebia os usuários de drogas. Em seguida, se dirigia até DANIEL, que estava mais no fundo da viela, pegava o entorpecente e entregada aos usuários.

Relataram que a dinâmica se repetiu por aproximadamente três vezes, motivo pelo qual efetuaram a abordagem dos réus, os quais confessaram a prática do tráfico de drogas.

Declararam que em revista pessoal não localizaram nada de interesse policial com o réu LEONARDO. No entanto, com DANIEL, os agentes encontraram drogas e dinheiro.

E as falas dos policiais, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições, se cotejadas com os depoimentos prestados, por eles, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

“De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016” (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

“o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para

desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade" (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

"No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais" TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

A testemunha Larissa Barreto Gomes Soares, esposa do acusado Leonardo, disse que o réu é usuário de drogas, está sumido e que ele sempre desaparece e volta. Declarou que Leonardo disse que faz pequenos bicos para pagar pelas drogas.

O réu DANIEL disse que é usuário e que estava na biqueira quando um traficante pediu para que permanecesse no local, traficando drogas, por breve período, pois logo voltaria. Esclareceu que LEONARDO já trabalhava de campana na biqueira e que o avistou no local em outras oportunidades.

Asseverou que está trabalhando e não possui passagem infracional.

O acusado LEONARDO não foi interrogado porque revel.

Pois bem.

A imputação Ministerial, quanto à tipicidade da conduta dos acusados, é passível de acolhimento porque restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas que os réus, de fato, estavam a praticar a traficância.

Isso porque está clara a prática do que traz o tipo previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, por parte da ré, na medida em que levavam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ora, os entorpecentes eram levados pelos réus, que os detinham especialmente para o fim de cometer a traficância.

Os depoimentos prestados pelos policiais foram uníssonos e harmônicos ao descreverem as diligências realizadas durante o ocorrido, o que fica reforçado ao se considerar a confissão do acusado DANIEL.

Deveras, "os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Assim, diante dos elementos de convicção e das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o proceder dos acusados se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial acusatória, sendo suas condenações quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno LEONARDO DE OLIVEIRA GODINHO SOARES e DANIEL RODRIGUES MALTA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Na primeira fase da dosagem não há nada a ser considerado.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do CP), motivo pelo qual reduzo a pena do acusado DANIEL em 1/6, anotando-se, contudo, o teor da Súmula 231 do STJ, no sentido de que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

E, na terceira fase, de aplicação da pena, aplico ao réu DANIEL a causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, à razão de 2/3, já que o acusado em questão é tecnicamente primário e não é portador de Maus Antecedentes, sem haver nos autos prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Ademais, referido acusado colaborou com a instrução penal, compareceu na audiência espontaneamente, malgrado não tivesse sido localizado, bem como esclareceu a participação do corréu no crime e informou que está trabalhando.

Por outro lado, o acusado LEONARDO não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto.

Isso porque a prova oral demonstra que LEONARDO já traficava drogas em datas anteriores.

Tal fato demonstra que o réu tem se dedicado à atividade criminosa, circunstância apta a afastar a possibilidade de aplicação da causa de redução em comento.

E é evidente que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, hipótese com a qual, repita-se, não se identifica o caso vertente.

Nesse sentido, verifique-se o seguinte trecho do excelente voto condutor prolatado pelo Excelentíssimo Desembargador Geraldo Wohlers, em v. acórdão que confirmou condenação proferida por este magistrado, na Comarca de Serrana:

"A diminuição hoje admitida pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas".

Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de

regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

No âmbito desta Colenda Câmara, consignou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)”. (TJ/SP; Ap. 0003339-42.2011.8.26.0596; OJ 3ª Câmara de Direito Criminal: DJ 04/12.12) (destaquei)

Por tudo isso e se considerando sobremaneira que há provas suficientes de que se dedica a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.

Assim, para o acusado LEONARDO, chego à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei

E, para o réu DANIEL, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

Diante das especificidades do caso concreto, excepcionalmente considero cabível o regime ABERTO para início do cumprimento para o réu DANIEL.

Quanto ao réu LEONARDO, o regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, diante da gravidade do delito em questão, da pena aplicada e, notadamente, dos indicativos de que integra atividade criminosa.

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juízes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que “diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão.” Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Considerando a gravidade do crime, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do “sursis”.

Deveras, tais benefícios não são compatíveis, concretamente, com a necessária reprovação e a indispensável prevenção da conduta incriminada.

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente (prevenção específica).

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da edição da Resolução 5/2012 do Senado Federal suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direito” do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, baseio-me no entendimento no sentido de que o art. 44 da Lei de Drogas não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição fia-se no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo se tratando de tráfico de drogas sem majorantes, a hediondez do delito não está afastada.

Não bastasse isso, é de se ter em conta que seria um verdadeiro absurdo que, concretamente, fosse a pena privativa de liberdade substituída por outra restritiva de direitos, já que isso tornaria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância entorpecente muito próxima.

Por isso, com a devida vênia dos que pensam diferentemente, repudio o entendimento de que, a não ser em casos específicos e isolados, tal substituição seja possível, ainda quando a quantidade de pena concretamente imposta não seja suficiente para afastar o benefício.

Impossível a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não há informação nos autos sobre eventuais prejuízos financeiros experimentados pela sociedade.

Se a providência já não foi deferida, autorizo, agora, a destruição da droga apreendida.

Nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento de dinheiro e objeto apreendidos, se o caso.

No mais, verifico que é o caso de acolhimento do pedido de prisão preventiva do acusado LEONARDO, pois o réu descumpriu a medida cautelar aplicada por ocasião da audiência de custódia, pois, mesmo ciente de que deveria comparecer a todos os atos do processo e que não poderia se ausentar da comarca sem prévia notícia, tomou rumo

ignorado, deixando, inclusive, de comunicar o local onde poderia ser encontrado ou o seu endereço contemporâneo, além de não ter comparecido na audiência designada.

Nesse ponto, anoto que o Oficial de Justiça diligenciou nos endereços informados pelo acusado nos autos, mas não conseguiu efetuar a intimação do réu (fls. 148).

Portanto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO DE OLIVEIRA GODINHO SOARES, qualificado nos autos, nos termos do artigo 282 e artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

O réu DANIEL poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a pena aplicada.

Nome no rol, oportunamente.

Aos defensores nomeados, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidões, oportunamente.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA